

第29問

以下の事例における甲、乙及び丙の罪責について、論じなさい。

- (1) 甲は、Aから自殺しようとしていることを打ち明けられ、協力するよう頼まれた。甲は、Aの決意が固いことから、これを承諾し、1錠飲めば苦しむことなく死ぬ毒薬を用意し、Aに交付した。

Aは、これを受け取った日の夜、自宅で毒薬を飲もうとコップに水を汲んだが、やはり死ぬのは恐いと思い直し、結局、毒薬を飲むことはなかった。

- (2) 乙は、B宅へ行き、2人で酒を飲んでいたら、Bから「俺なんか、生きていても仕方がない。昨日、自殺しようとしたが自分ではできなかった。」と打ち明けられた。乙は、Bの話を聞き、自分がBを殺すようお願いされていると思い込み、Bが寝たところで、B宅にあった包丁を取り出して、Bを刺殺した。しかし、Bは、乙に、自分を殺害して欲しいとは思っていなかった。

- (3) 丙は、友人Cと仲たがいのことから、同人を殺してやろうと考え、C宅の前でCを待ち伏せし、CがC宅から出てきたところを予め用意しておいたピストルで射殺した。しかし、Cは自分の経営する会社が倒産したことから、死にたいと思っており、丙に対して自分を殺すよう依頼するメールを送っていたが、丙はこのメールに気が付いていなかった。

第1 小問(1)について

甲には自殺幇助罪（202前段）の成立が考えられるが、Aが自殺に着手していないから、同罪の着手時期が問題となる（**論点** 自殺関与罪（同意殺人罪）の処罰根拠（減軽根拠）、**論点** 自殺関与罪の着手時期）。

この点については、幇助行為の開始時点であるとする立場と自殺行為の開始時点であるとする立場が対立しており、いずれの見解に立つのかによって結論が異なる。

総合 168 頁 論証 68 頁
総合 168 頁 論証 68 頁

第2 小問(2)について

乙は、客観的には普通殺人罪（199）を行っているものの、主観的には嘱託殺人罪（202後段）の故意を有するにとどまる（**論点** 同意殺人罪における承諾と錯誤 **補** 予R3）。

この点については、法定的符合説の立場に立った場合には、乙に対しては、嘱託殺人罪が成立するに止まることになる（大判明43.4.28参照）。

総合 168 頁 論証 69 頁

第3 小問(3)について

本小問は小問(2)と逆に、主観的には普通殺人罪の認識を有するものの、客観的には嘱託殺人罪を行っているにすぎない。

このような場合について、学説は、殺人既遂罪説、殺人未遂罪説、同意（嘱託）殺人罪説に分かれる（**論点** 同意殺人罪における承諾と錯誤 **補** 予R3）。

総合 168 頁 論証 69 頁

答案構成

第1 小問(1)について

- 1 自殺幫助未遂罪（203、202前段）の成否

↓

- 2 実行の着手時期（43本文）

↓

自殺関与罪は独立の犯罪類型

↓

幫助行為の開始に実行の着手がある

↓

- 3 甲には自殺幫助罪の未遂が成立する

第2 小問(2)について

- 1 客観的には殺人罪（199）に該当するが、主観的には嘱託殺人罪（202後段）の故意を有するに過ぎない

↓

- 2 重い殺人罪で処断することはできない（38Ⅱ）

↓

- 3 軽い嘱託殺人罪の限度で処断することはできないか

↓

抽象的事実の錯誤

↓

法定的符合説

↓

あてはめ

↓

- 4 乙には嘱託殺人罪が成立する

第3 小問(3)について

- 1 客観的には嘱託殺人罪に該当するが、主観的には殺人罪の故意を有する

↓

- 2 普通殺人人に向けての実行行為性が認められない

↓

およそ殺人罪は成立しない

↓

- 3 抽象的事実の錯誤

↓

法定的符合説

↓

あてはめ

↓

丙には嘱託殺人罪が成立する

第1 小問(1)

1 甲にはAを「幫助して自殺させ」ようとしたものとして、自殺幫助罪（202条前段）の成立が考えられるが、結局、Aは自殺に着手していない。

同罪の実行の着手時期（43条本文）を幫助行為の開始時と捉えた場合、同罪の未遂（203条）が成立するのに対し、被幫助者の自殺行為の開始時と捉えた場合、未遂も成立しない。

そこで、同罪の実行の着手時期が問題となる。

2(1) この点について、自殺幫助罪が共犯の特別類型であると考えられるならば、自殺者の自殺行為の開始に実行の着手時期を求めるべきことになる。

しかし、自殺は自己決定権の表れとして、違法性が阻却され犯罪というべきではない。そうすると、自殺幫助罪は共犯の特別の類型ではないことになる。

(2) とはいえ、生命は本人だけが左右し得るものであり、他人の自殺への関与は生命への干渉として可罰性があるといえる。

このように自殺幫助罪は独立の犯罪類型として処罰の対象となると解する。すなわち、自殺幫助罪は、幫助行為を独立の犯罪行為として処罰したものといえる。そうすると、幫助行為こそが実行行為であると解するのが自然である。

したがって、幫助行為の開始に実行の着手があると解する。

3 以上から、甲には自殺幫助罪の未遂が成立する。

1

第2 小問(2)

1 Bは、乙に、自分を殺害して欲しいとは思っていなかったのだから、乙は、客観的には殺人罪（199条）の構成要件に該当する行為をしている。一方、主観的には殺害についてのBの「囑託」があると誤信し、囑託殺人罪（202条後段）の故意を有している。

2 ここで、行為者が囑託の存在を誤信し、人を殺害した場合、軽い罪を犯す意思で重い罪を犯しているといえる。この場合、重い殺人罪で乙を処断することはできない（38条2項）。

3 一方、軽い囑託殺人罪の限度で乙を処断することはできないか。これは抽象的事実の錯誤の問題である。

故意責任の本質は、犯罪事実の認識によって反対動機が形成できるのに、あえて犯罪に及んだことに対する道義的非難である。そして、犯罪事実は刑法上構成要件として類型化されているから、構成要件該当事実の認識がなければ反対動機の形成可能性がなく、原則として故意は阻却されるということになる。

ただし、構成要件に実質的な重なり合いが認められる場合には、その限度で反対動機を形成することができる。したがって、そのような場合には、その限度で故意責任を問うことができると考える。かかる実質的重なり合いの有無については、①両罪の行為態様、及び②被侵害法益の共通性をもって判断すべきである。

囑託殺人罪は殺人罪の減軽類型とみ得るから、①②の共通性が認められる。

2

したがって、乙は嘱託殺人罪の限度で罪責を負う。

4 以上から、乙には嘱託殺人罪が成立する。

第3 小問(3)

1 Cは丙に対して自分を殺すよう依頼するメールを送っていたのだから、「嘱託」がある。そのため、丙の行為は客観的には嘱託殺人罪の構成要件に該当する。一方で、丙は、殺害についての「嘱託」を認識していないから、主観的には殺人罪の認識を有している。

2 このような場合、まず、被害者の意思に反して生命を奪うという客観的危険性が存在しない以上、普通殺人人に向けての実行行為性が認められないというべきである。

したがって、殺人罪はおおよそ成立し得ないと解する。

3 この問題は、重い罪を犯す意思で軽い罪を犯した場合として、抽象的事実の錯誤の一種として処理するべきである。

本小問でも、第2と同様に、軽い嘱託殺人罪の限度で故意が認められるから、丙は同罪の罪責を負う。

以 上

3

4